

1508202-18.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/06/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1508202-18.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508202-18.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2096527/2022 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 24165750 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2096527 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

MARCELO APARECIDO BENEDITO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

ALEXANDRE VILLANUEVA DA SILVA FILHO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, porque no dia 07 de abril de 2022, por volta das 12h12, na Rua Alfredo Pereira dos Santos, altura do nº 32, Brasilândia, nesta cidade e comarca de São Paulo/SP, guardava, 171 (cento e setenta e uma) porções de Tetrahydrocannabinol (THC), substância popularmente conhecida como "maconha", pesando no total 672,5 g (seiscentos e setenta e dois gramas e cinco decigramas; e 150 (cento e cinquenta) porções de cocaína, na forma de "crack", com peso total de 50,8g (cinquenta gramas e oito decigramas),

substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal.

Em 20 de abril de 2022 houve a determinação para a notificação do réu e apresentação de defesa preliminar (fls. 78/84).

O réu foi notificado (fls. 116) e ofertou defesa preliminar às fls. 120. A denúncia foi recebida em 23 de maio de 2022 (fls. 123) e o réu foi devidamente citado em audiência.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pela acusação e defesa, sendo, em seguida, o réu interrogado. Não foram requeridas diligências pelas partes.

Em debates orais, a representante do Ministério Público reportou-se ao contido nos autos, pedindo a condenação do réu nos termos da denúncia, com observância de sua reincidência na fixação da pena.

O Defensor nomeado postulou a fixação da pena-base no mínimo legal, compensação da reincidência com a confissão, fixação de regime semiaberto, detração e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão estatal deve ser julgada procedente.

Os policiais militares narraram que estavam em patrulhamento de rotina em região conhecida pela alta incidência de tráfico de droga, onde costumam ficar diversos olheiros. Ouviram um rapaz gritar “molhou” e sair correndo na direção da viela na qual posteriormente o réu foi abordado, mas ele não ingressou em tal viela, mas em uma anterior, segundo o policial Fernando. Estacionaram a viatura, sendo que o policial Samuel nela permaneceu para fazer a segurança e o policial Fernando foi na direção da viela, na qual existe um portão fechado com chapa. Aproximou-se e conseguiu observar pela fresta do portão e também conseguiu ouvir que havia pessoas do lado de dentro conversando, mas não conseguiu ouvir exatamente sobre o que conversavam. Ficou aguardando e após algum tempo o portão se abriu, dali saiu um casal, juntamente com o réu, que segurou o portão. O casal saiu andando e o réu, ao perceber a presença policial, tentou fechar rapidamente o portão, mas o policial Fernando conseguiu segurar o portão, tendo visto que o réu trazia na mão uma pequena bolsa. O policial Samuel disse que escutou ordem de parada emanada por seu colega, motivo pelo qual desembarcou na viatura e se aproximou. Em revista pessoal, Fernando encontrou com o réu um aparelho celular e dentro da bolsa que o réu carregava 150 porções de crack e 170 de maconha, além da quantia de cerca de R\$ 570 em notas trocadas. Samuel relatou que quando se aproximou, seu colega já havia feito a abordagem do réu e que ao lado dele havia uma pequena bolsa, dentro da qual havia drogas. Para Fernando o réu confessou que estava traficando. Perante Samuel o réu nada falou sobre as drogas. Ele reside nas proximidades, sendo que parentes dele compareceram no local, mas não falaram diretamente com os componentes da guarnição. Samuel não conhecia o réu anteriormente e Fernando já o havia abordado anteriormente, mas nunca o prendeu, sendo que nunca houve qualquer problema nas abordagens anteriores. Ele não parecia estar sob efeito de drogas e com ele não havia qualquer apetrecho para consumo de drogas. Colocaram o réu na viatura e foram à procura do casal que havia saído do local momentos antes, sendo que o encontraram em uma rua próxima. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com quaisquer deles. Ela disse que estava indo encontrar uma amiga e ele disse que a estava acompanhando.

O réu, em seu interrogatório, confessou a prática delitiva, afirmando que estava trabalhando cortando cabelos, mas estava passando dificuldades financeiras. No dia dos fatos, ofereceram-lhe para vender drogas no local, perto da casa de sua avó, onde estava passando alguns dias. Ganharia R\$ 100,00.

Assim, é de se concluir pela existência da prática de tráfico pelo réu, o que se extrai da conjugação dos seguintes fatores: quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, que estavam fracionadas e prontas para a entrega a usuários; a incompatibilidade entre a quantidade de drogas e a condição financeira do réu; ausência de demonstração que a droga destinava-se para seu consumo próprio; a prisão ocorreu em um local conhecido como ponto de tráfico; as circunstâncias da prisão em flagrante, sendo que o policial Fernando visualizou o réu segurando a

bolsa que continha os entorpecentes; a localização de dinheiro em notas trocadas em poder do réu; confissão do réu Em Juízo.

Em caso análogo já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"TESTEMUNHA - Tóxico - Depoimentos prestados por policiais - Validade - Inexistência de razão concreta para suspeição - Relatos que merecem a normal credibilidade das testemunhas em geral - Interpretação do artigo 202 do Código de Processo Penal - Recurso não provido.

PROVA CRIMINAL - Tóxicos - Drogas apreendidas na residência da ré que não produziu qualquer prova de que não fossem de sua propriedade - Recurso não provido.

PROVA CRIMINAL - Tóxicos - Casa conhecida como local de venda de entorpecentes, quantidade e acondicionamento da droga apreendida que nenhuma dúvida deixam a respeito da destinação comercial do produto - Recurso não provido." (Ap. Crim. nº 247.848-3 - São Paulo - 6ª Câm. Crim. de "Julho/98" - Rel. Debatin Cardoso - J. 13.08.98 - v.u).

Os policiais ouvidos procederam a relatos detalhados, uníssonos e harmônicos entre si, ratificando-se o que falaram na fase policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Trata-se de agentes públicos, dotados de fé pública, aos quais são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor.

A palavra deles não merece descrédito, tendo em vista que o réu não noticiou que os conhecia anteriormente, inexistindo motivos para que eles pretendessem legitimar a prisão realizada. São agentes públicos dotados de presunção de boa-fé, até prova em contrário, cuja produção estaria a cargo da defesa, que não se desincumbiu de tal ônus nestes autos. Não seria coerente conferir-se ao policial a presunção de legitimidade para realizar as funções que lhe compete, como a de policiamento ostensivo e abordagem a suspeito, para depois, em Juízo, extrair-se de suas palavras a validade necessária. Esclarecedora a seguinte transcrição

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO. (...)

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso" (STJ, HC 165561 / AM, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 02/02/2016)

Observo que pequenas contradições, não essenciais aos fatos, apenas ratificam a veracidade de seus depoimentos, pois indicam de forma clara que não houve prévio ajuste sobre a versão que deveria ser ofertada, baseando-se seus relatos exclusivamente na memória que têm do dia dos fatos.

A materialidade delitiva está comprovada pelo exame químico-toxicológico de fls. 93/95, que atestou positivamente para cocaína e tetrahydrocannabinol (THC), além do auto de exibição e apreensão (fls. 14/15).

Irrelevante que o réu não tenha sido surpreendido comercializando os entorpecentes, pois se trata de tipo misto alternativo, bastando a prática de qualquer dos seus verbos nucleares para sua configuração, sendo que no presente caso guardava, as drogas supramencionadas.

Forçosa, destarte, a condenação do réu nos termos acima expostos. Passo à DOSIMETRIA DA PENA.

Observando-se os elementos norteadores contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal e ainda o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, dada a natureza nociva de um dos entorpecentes encontrados em poder do réu (crack) a revelar elevado e devastador efeito psicotrópico, tratando-se de drogas com alto poder viciante, autoriza-se a fixação da pena acima do mínimo legal, vez que tais circunstâncias excedem o

desvalor inerente ao tipo. Anoto que a jurisprudência vem na linha do entendimento do juízo, confira-se: "A natureza nociva da substância entorpecente apreendida - cocaína - constitui fundamentação idônea a ensejar maior apenação na primeira etapa da dosimetria, pela desfavorabilidade das consequências do delito." (HC 141092/MS). Assim, majoro a pena-base do réu em 1/6, ficando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. O réu é reincidente específico pela 1ª Vara Criminal do Foro de São Roque (autos nº 1501294-68.2017.8.26.0586 - trânsito em julgado para defesa em 08/10/2019 - fls. 114) e confessou integralmente a prática delitiva. Esta magistrada adota o entendimento de que no concurso da agravante da reincidência e da atenuante da confissão deve prevalecer aquela, nos termos do artigo 67 do Código Penal. No entanto, o STJ, quando do julgamento do tema 585 em recurso repetitivo (RESP nº 1.341.370-MT) assentou o entendimento de que deve haver compensação de tais circunstâncias, motivo pelo qual, nesta segunda fase da dosimetria, a pena remanescerá inalterada.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º da Lei Antidrogas, tendo em vista que se trata de réu reincidente específico.

Quanto ao regime de pena, declarada a inconstitucionalidade incidental do preceito legal que determina a adoção de regime inicial fechado (STF, HC 111.840/ES), passa-se à análise da questão. Com efeito, entende-se que seja aplicável regime mais severo do que aquele que o seria com base no simples valor aritmético da pena ora aplicada. Isto porque, trata-se de réu reincidente específico e que estava em cumprimento de pena quando tornou a delinquir (fls. 114), e, ainda, a gravidade em concreto do delito em questão, justifica o regime fechado, tendo em conta a relevante diversidade dos entorpecentes apreendidos, representando maior risco para a sociedade, pois causador de maior dependência química, sendo assim mais nocivo para a saúde pública, bem jurídico tutelado pelo legislador. Frise-se, por fim, que o delito ora em questão é daqueles que mais desassossego traz para a sociedade paulistana, tendo em vista ser crime potencializador de outros delitos, já que boa parte dos agentes comete crimes sob efeito de drogas ou para quitação de dívidas oriundas da aquisição de entorpecentes. Neste sentido: STJ, RHC 37.637/SP, 5ª Turma, rel. Min. Moura Ribeiro.

Deixo de aplicar o artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.736/2012, por entender que tal dispositivo é impossível de ser aplicado no Juízo de primeiro grau. A progressão de regime é matéria atinente ao Juízo das execuções criminais, devendo ser aferido não apenas o tempo de cumprimento da pena, como também se o sentenciado possui mérito para a progressão. Além disso, considero tal dispositivo inconstitucional, uma vez que viola os princípios da isonomia e da individualização da pena. Ao se considerar somente o tempo de prisão provisória para a fixação do regime inicial, aquele que ficou solto durante o processo é tratado de forma prejudicial com relação àquele que ficou preso, uma vez que este poderá ter direito ao regime inicial mais benéfico tendo como base apenas o tempo de pena cumprido provisoriamente.

As condições econômicas do réu são modestas, assim fixo o valor de cada dia-multa no piso legal.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, o réu ALEXANDRE VILLANUEVA DA SILVA FILHO, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

As mesmas razões que recomendaram a custódia do acusado no curso do feito permanecem ainda presentes, vendo-se ainda reforçada a necessidade da cautela uma vez que, determinada a imposição de penas ao acusado, patente o risco de que solto venha procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga. Ademais, trata-se de réu reincidente específico, o qual estava em liberdade condicional quando da prática do delito apurado no presente feito (26/08/2021 - fls. 113/114), a indicar que sua liberdade seja um risco para a ordem pública. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra recolhido.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual, deferida ao réu às fls. 123.

Oficie-se para destruição do entorpecente apreendido independentemente de trânsito em julgado.

Tendo em vista que o dinheiro encontrado com o réu não teve sua origem lícita demonstrada nos autos, estando nitidamente atrelado ao tráfico de entorpecentes, em razão da sentença condenatória ora proferida, determino seu perdimento nos termos da lei. Oportunamente, oficie-se para transferência do valor e, nos termos do COMUNICADO CG Nº. 805/2019 da E. Corregedoria Geral da Justiça, oficie-se para comunicação sobre o perdimento, encaminhando-se o ofício para a Esplanada dos Ministérios, Bloco T – Ministério da Justiça e Segurança Pública, Edifício Sede, sala 208, Brasília, Distrito Federal, CEP: 070064-900.

Comunique-se à VEC a prolação da presente sentença.

P.R.I.

São Paulo, 23 de junho de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA